

1500496-39.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... acusar de trazer com eles e guardar drogas, para tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500496-39.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500496-39.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 24813221 - 01º D.P. AMERICANA, 2124498/2022 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 2124498 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

LUCAS BATISTA DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

JOSEMAIK DE OLIVEIRA SANTOS e FERNANDO SOARES MACHADO estão sendo processados como incursos nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, acusados de no dia 06 de maio de 2022, por volta de 23h45, na Rua São Rafael, 79, bairro Belvedere, nesta cidade, agindo em concurso e unidade de desígnios entre eles, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, guardarem e trazerem com eles, para serem entregues ao consumo de terceiros, 189 (cento e oitenta e nove) porções da droga cocaína, pesando cerca de 176g (cento e setenta e seis gramas), 81 (oitenta e uma) porções da droga conhecida como maconha (tetrahydrocannabinol), pesando no total cerca de 2.852g (duas mil, oitocentos e cinquenta e dois gramas) e 162 (cento e sessenta e duas) porções da droga conhecida como crack, forma sólida da cocaína, pesando cerca de 40g (quarenta gramas), substâncias estas causadoras de dependência química, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2022 (fls. 260/261).

Na instrução foram inquiridas três testemunhas comuns e três testemunhas de Defesa. Ao final, os réus foram interrogados.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia, com as condenações dos réus, provadas as ocorrências dos crimes, em concurso de agentes; materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime.

A Defesa de Josemaik, em memoriais, pleiteou a absolvição, garantindo inexistentes provas. Ele negou envolvimento no crime, as drogas localizadas na residência de Fernando foram por ele assumidas. Já as drogas encontradas dentro do veículo do acusado pertenciam a Sabrina. Os entorpecentes estavam dentro da bolsa da mulher, que os dispensou quando os policiais chegaram. Requeria nova oitiva da testemunha para esclarecimento desses fatos. Não praticava mercancia no momento da prisão. A versão foi abonada pelo corréu. Invoca o princípio 'in dubio pro reo'. Requer liberação do veículo apreendido e que pertencia à esposa do Josemaik (fls. 362/375).

A Defesa de Fernando também reclama absolvição. Fernando confessou integralmente a propriedade dos entorpecentes que se encontravam em sua residência e não obstaculizou o trabalho dos policiais. Ele se justificou ao detalhar que havia pegado os entorpecentes de um terceiro há poucos dias, para ganhar dinheiro, passava por dificuldades financeiras. Para o caso de condenação, pena mínima e regime brando, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Fernando também pretende redução da pena, prevista no artigo 33, par. 4º. Por fim, requereu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 376/398). É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, indefiro o pedido da Defesa para reinquirição da testemunha Sabrina, ouvida sob o crivo do contraditório. Eventual valoração quanto a veracidade do quanto alegado é questão de mérito e inexistentes outros elementos, salvo a discordância da Defesa quanto ao conteúdo, não amparam nova inquirição. A denúncia é procedente, na íntegra.

Preso em flagrante, Josemaik alegou que conhecia o Lucas e o correu, Fernando. Combinou com o Lucas de irem até uma tabacaria. Foram com o seu veículo, lá se encontraram Vitor e Sabrina, saíram todos juntos no veículo. Também havia combinado de sair com o Fernando. Passou na casa dele e enquanto estava na residência apareceram policiais no local, encontrando drogas. Nada lhe pertencia, tudo era de responsabilidade do Fernando. Desconhecia as drogas ditas que estavam em seu poder, em seu carro (fls. 15).

Perante a autoridade policial, Fernando confirmou que estava em sua casa, juntamente com o Josemaik. Pelo local, apareceram policiais e que de fato localizaram drogas e dinheiro no imóvel. Admitiu que estava vendendo as drogas por dificuldades financeiras. As outras pessoas nada sabiam sobre os entorpecentes (fls. 17).

Em Juízo, Josemaik alegou que na véspera dos fatos Fernando o convidou para irem até uma tabacaria. No período da noite, foi até a casa do pai do Lucas. Combinou com o Lucas de irem na Tabacaria na sexta-feira, por volta das 21 horas. Em seguida foram na empresa, subiu na fábrica para soltar os cachorros. Encontrou o Vítor e a Sabrina na Tabacaria. Lucas os conhecia, parou perto deles para conversar, enquanto foi direto no balcão para fazer o seu pedido. Lucas convidou os seus conhecidos para ficarem na mesma mesa. Permaneceram por aproximadamente quarenta minutos na tabacaria. Posteriormente, Fernando enviou mensagem de que já tinha saído do trabalho na pizzeria. Chamou o Lucas para irem buscá-lo. Vítor e a Sabrina perguntaram onde iriam e respondeu que dariam um 'rolê', pedindo eles carona até a Avenida. Respondeu que daria carona, mas antes precisava buscar o Fernando, que estava na casa dele. Lucas voltou no banco da frente do veículo, ao seu lado. Parou na frente da casa do Fernando e desceu do carro, Lucas foi para o banco de trás. Fernando gritou que o portão estava aberto e o convidou para entrar e esperar, estava tomando banho. Em seguida, disse para irem embora porque amigos do Lucas o

aguardavam no carro, iria dar uma carona para eles até a Avenida. Enquanto o Fernando terminava de se trocar, usou o banheiro dele. Assim que saíram, foram abordados pelos policiais, que determinaram que colocassem as mãos na cabeça. Portava apenas dinheiro e um aparelho celular no bolso. Fernando disse para os policiais que tinha ilícito e exibiu uma bolsa, com maconha. Ele também apontou drogas embaixo do armário e um dinheiro, dentro do quarto. Os policiais localizaram mais de R\$ 1.000,00 no dormitório. Não tinha nada a ver com as drogas. Os policiais o algemaram, disseram que seria levado como testemunha. Explicaram que provavelmente o Fernando ficaria preso, pois ele era o dono da droga. Na ocasião, alegou para os policiais que poderia acompanhá-los com o carro da sua esposa. Não tinha drogas em seu poder ou com o Lucas. A droga apareceu na delegacia. Não podia afirmar que os policiais colocaram os entorpecentes no seu carro, que tinha o tampão aberto. Encontraram drogas no porta-malas e no assoalho do veículo, espalhadas. Não podia afirmar quem as colocou ali, mas não lhe pertenciam. Trabalhava como encarregado de produção têxtil, tinha três filhos. Acompanhou as buscas realizadas na casa do Fernando, os policiais encontraram maconha em uma bolsa. Viu quando os militares localizaram debaixo do armário algumas porções de cocaína e de crack.

Sob o crivo do contraditório, Fernando relatou que convidou o Josemaik para saírem. Trabalhava como motoboy, em um restaurante americano e na "Pizzaria Buenos", aos finais de semana. Assim que terminou o turno na pizzaria, falou para o Josemaik que iria em sua casa para tomar um banho e se arrumar. Disse que ele poderia ir buscá-lo. Enquanto tomava banho, Josemaik o chamou. Alegou que ele poderia entrar e pediu para que encostasse o portão, pois já terminava o seu banho. Foi se arrumar e colocar o tênis em seu quarto, quando ouviu uma voz dizendo "mão na cabeça, tem gente na casa?". Tirou a meia e foi até a porta do quarto, oportunidade que se deparou com os policiais. Explicou que não tinha outras pessoas na casa. Foi revistado e levado para a sala. Informou que tinha maconha em uma bolsa, no rack. Os policiais acharam mais algumas coisas e o prenderam por tráfico de drogas. Confidenciou que pegou os entorpecentes há cinco dias, para guardá-los. Morava com a sua irmã, era motoboy e estava com uma plataforma de roupas, que comercializava nas redes sociais. Passava um aperto, por causa do aluguel, por isso aceitou guardas as drogas. O dinheiro localizado era para pagar a documentação da sua moto. Faria a emissão da sua habilitação na segunda feira, para continuar com os seus trabalhos e não perder a moto, que estava com os pneus 'careca'. Sua irmã cuidava da sua sobrinha, ela não estava em casa. Guardou a bolsa com as drogas no rack, tinha um sentimento ruim, iria devolvê-las. Disseram que era pouca quantidade, procurava uma forma de falar com quem as deixou, mas não teve tempo. Estava arrependido. Toda a droga encontrada na casa era da sua propriedade, Josemaik não tinha nada a ver com os entorpecentes. Apenas daria uma volta com o Josemaik, as drogas não pertenciam a ele, apenas combinaram de sair. Josemaik era uma pessoa trabalhadora.

A negativa do réu Josemaik não convence e foi desmentida pela prova testemunhal. Lucas Batista da Silva, inquirido na Delegacia, esclareceu ser usuário de maconha. Foi até a "Tabacaria American Gardens", na companhia do amigo do seu pai, "Maik", que conduzia o veículo GM/ Celta, de cor prata. No estabelecimento, encontraram o Vitor, com quem jogava bola. Lucas estava com a Sabrina. Em seguida, decidiram ir até outra tabacaria, em Limeira. Durante o trajeto, "Maik", parou o veículo e pediu para esperarem ali, que ele iria até a casa de um amigo. Ficou no interior do veículo, juntamente com o Vitor e a Sabrina. Enquanto aguardavam o retorno de 'Maik', foram abordados pelos policiais militares. Eles pediram para deixarem o veículo. O carro foi vistoriado e foi localizado no interior do veículo algumas porções de maconha. Desconhecia a existência da droga ali encontrada. Vitor alegou que não sabia o que foi encontrado com ele. Os policiais perguntaram a quem pertencia as drogas localizadas no interior do veículo, negou serem de sua propriedade. Vitor e a Sabrina também disseram que não eram deles as drogas encontradas no veículo. Explicou para os policiais que o 'Maik' foi até a casa de um amigo, nas imediações, mas não apontou a casa, não sabia qual era. Os policiais militares fizeram diligências e localizaram a residência, que estava com portão

entreaberto. No imóvel, localizaram o "Maik" e o amigo dele, morador da residência, não sabia o nome dele. Os policiais saíram de dentro da casa com objetos, mas não sabia o que realmente foi localizado. Em seguida, todos foram conduzidos até a Delegacia (fls. 13).

Vítor Hugo Ongaro, primeiro no inquérito, afirmou ser usuário de drogas. Conheceu Sabrina em uma casa de eventos, conversavam pelas redes sociais. Na data, combinaram de se encontrar na "Tabacaria American Gardens". Enquanto conversavam, chegaram os colegas 'Maik', que havia conhecido naquele estabelecimento, três semanas antes e o Lucas, com quem jogava bola. Em dado momento, resolveram sair da tabacaria para irem na casa de eventos 'Bull'. No trajeto, 'Maik', parou o veículo no bairro São Vito e foi até a casa de um amigo. Permaneceu no interior do veículo, juntamente com o Lucas e a Sabrina. Enquanto aguardavam o retorno do proprietário do automóvel, foram abordados pelos policiais militares. Durante a revista veicular, os policiais localizaram algumas porções de maconha, além de 02 (duas) porções de maconha que trazia em seu poder, para o seu consumo.

Os policiais perguntaram sobre a propriedade das drogas localizadas no interior do veículo, Lucas e Sabrina negaram que fossem deles. Explicou que o condutor do carro, Maik, foi até a casa de um amigo ali próximo, mas não sabia identificar qual era o imóvel que ele entrou. Os policiais militares fizeram diligências e avistaram uma residência com o portão entreaberto, oportunidade em que encontraram o Josemaik e o amigo dele, atual morador da residência. Os policiais saíram do imóvel com uma sacola plástica, com certa quantidade de drogas (fls. 11).

Sabrina da Silva Dutra sustentou no depoimento judicial que conheceu o Vítor em uma tabacaria, não sabia o bairro em que ele morava. Não conhecia os acusados. Conversava com o Vítor pelo celular, mas em determinado dia ele combinou de se encontrarem na tabacaria. Vítor estava com dois amigos, Lucas e o Josemaik. Vítor ofereceu carona para irem embora. No meio do caminho, Josemaik disse que passaria na casa do Fernando. Ele parou na frente da casa dele e desembarcou do veículo. Nesse momento, chegou a viatura. Os policiais determinaram que descessem do carro. Lucas e o Vítor foram colocados do outro lado da rua para revistarem o veículo. Foi questionada sobre o paradeiro do condutor do veículo, Josemaik. Respondeu que ele desceu em uma casa, que não sabia precisar qual era. O portão estava entreaberto e os policiais entraram. Não viu os policiais encontrarem drogas no carro do Josemaik. Desconhecia que o Vítor estivesse com drogas. Em seu poder, não foi encontrado nada de ilícito. Não conhecia o Fernando. Acreditava que o Lucas residia no Bairro Zabani.

Ivan de Oliveira, policial militar, ouvido em juízo e com a garantia do contraditório, esclareceu que no mês de maio, patrulhavam no bairro Jardim Belvedere quando avistaram um veículo Celta, de cor Prata, ocupado por três pessoas, parado na Rua São Rafael. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do veículo se abaixaram, tentaram se esconder, fato que chamou a atenção da equipe. Realizaram a abordagem, identificaram o Lucas, Sabrina e o Vítor, que estavam no banco de trás do carro. Não havia ninguém nos bancos da frente. Durante a revista, com o Vítor, localizaram 4 (quatro) porções de maconha e um celular. Em poder do Lucas encontraram, no assoalho do carro, próximo aos pés dele, 14 (catorze) porções de maconha e a quantia de R\$ 7,00 (sete reais). Sabrina portava apenas um aparelho celular.

Ao serem questionados, entraram em contradição. Na ocasião, Sabrina informou que o condutor do veículo havia entrado na casa numeral 79 para pegar mais algumas coisas, para darem 'um rolê'. O portão casa estava aberto, era uma edificação situada nos fundos. Ao acessarem o corredor, depararam-se com o Josemaik e o Fernando, que saíam da residência dos fundos. Josemaik se identificou como sedo o condutor do veículo, modelo Celta. Ao ser revistado, encontraram em seu bolso a quantia de 14 (catorze) porções de cocaína, além da quantia de R\$ 145,00 e um aparelho celular. Já com Fernando, que se identificou como proprietário do imóvel, nada de ilícito foi encontrado. Os acusados aparentavam nervosismo e foram contraditórios ao responderem as perguntas. Pela janela do corredor, que dava acesso à sala e a cozinha, foi possível ver uma balança de precisão, além de alguns

objetos que estavam em cima do balcão. Questionado, Fernando inicialmente negou qualquer ilícito na residência, posteriormente ele confessou que havia mais drogas dentro da casa, apontando os lugares em que poderiam ser encontradas. A equipe localizou uma mochila preta, embaixo de um hack, 2 (dois) tijolos de maconha, mais 4 (quatro) metades de maconha. Embaixo dos armários da cozinha encontraram drogas já embaladas, 174 (cento e setenta e quatro) porções de cocaína, 162 (cento e sessenta e duas) pedras de crack, 27 (vinte e sete) porções (pequenas) de maconha, 6 (seis) pedaços grandes de maconha e uma porção grande de um pó branco, aparentando ser cocaína a granel. Durante as buscas no imóvel foi localizado dentro de um tênis a quantia de R\$ 1.282,00, em dinheiro. Questionado, Fernando, morador da residência, assumiu a propriedade de todo o material. Na ocasião, também localizaram embalagens plásticas, peneira, plástico filme, próximos às drogas. Com o apoio de outras viaturas, realizaram nova busca minuciosa no veículo, localizando no porta-malas, próximo do estepe, mais 28 (vinte e oito) porções de maconha. Diante dos fatos, deram voz de prisão aos acusados, conduzindo-os ao plantão policial, juntamente com as três pessoas que estavam no carro, como testemunhas. Fernando assumiu a propriedade das drogas, que estavam dentro da casa dele. Josemak entrou em contradição em suas versões, não soube explicar a procedência dos entorpecentes que estavam no veículo e no bolso dele. A droga encontrada no assoalho do veículo, estava próxima do pé do Lucas, do lugar em que ele estava sentado.

Lucas negou a propriedade dessa droga. As drogas encontradas no porta-malas, próximo do estepe do veículo, estavam embaladas em dois kits. Naquela oportunidade a equipe realizava uma operação no bairro, não havia denúncia previa sobre aquele local ou a respeito daquelas pessoas. Realizaram a abordagem pela atitude suspeita dos ocupantes do veículo, todos estavam sentados no banco de trás e se abaixaram ao perceberem a aproximação da viatura.

Vítor Giacomo Ferreira Lourenço, outro policial, reiterou a versão do colega investigador. Destacou que a equipe de força tática realizava a operação 'São Paulo mais seguro', no bairro Jardim Belvedere, avistaram um veículo Celta, na cor prata, ocupado por três pessoas, todas sentadas no banco traseiro. Quando eles perceberam a aproximação da viatura, todos abaixaram-se, no intuito de se esconder, o que motivou a abordagem. Durante a revista, localizaram no bolso do Victor, 4 (quatro) porções de maconha e um aparelho celular. Já no bolso de Lucas foi encontrada a quantia de R\$ 7,00. Com o apoio de uma policial feminina, a Sabrina foi revistada, mas ela trazia apenas um aparelho celular. Questionados a respeito do que eles faziam naquele local, todos entraram em contradição. Sabrina informou que todos aguardavam o retorno do condutor do veículo, que entrou em uma casa logo à frente, de número 79. Notaram que o portão da casa indicada estava entreentreaberto. Entraram no imóvel e abordaram o Josemaik e o Fernando no corredor. Revistados, localizaram com o Josemaik 14 (catorze) porções de cocaína, R\$ 145,00 em espécie e um aparelho celular. Nada de ilícito foi localizado em poder do Fernando. A equipe conseguiu visualizar através da janela que no balcão da cozinha havia uma balança de precisão e um rolo de fita adesiva. Fernando, proprietário do imóvel, foi indagado se havia drogas no interior da casa e confirmou. Entraram no imóvel e encontraram uma bolsa de cor preta, que estava no rack da sala, com 2 (dois) tijolos inteiros, 4 (quatro) metades de tijolo de maconha. Na cozinha, embaixo do armário, foi localizado 174 (cento e setenta e quatro) porções de cocaína, 162 (cento e sessenta e duas) pedras de crack, 27 (vinte e sete) porções de maconha, 6 (seis) pedaços (médios) de maconha e uma porção de cocaína a granel. Sobre a mesa, havia duas peneiras, rolo de papel alumínio, rolo de saco plástico, além de vários, saquinhos oriundos do tráfico de drogas.

Dentro do tênis, que era de propriedade do Fernando, encontraram a quantia de R\$ 1.282,00, em dinheiro. Fernando, proprietário do imóvel, informou que estava na prática do tráfico de drogas para conseguir dinheiro. Com o apoio de outras viaturas de força tática, realizaram a busca veicular. No assoalho do banco traseiro em que o Lucas estava sentado, foi localizado 4 (quatro) porções de maconha. No porta-malas, encontraram 14 (catorze) porções de maconha. Diante dos fatos, todos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, para deliberações

da autoridade policial, que ratificou a voz de prisão aos acusados. Os outros três abordados, foram ouvidos e liberados. As drogas, o dinheiro, o veículo e os demais objetos ficaram apreendidos. Josemaik não disse nada. As drogas localizadas no porta-malas do veículo estavam acondicionadas dentro de um saquinho, em forma de kit. Não conhecia os acusados. Era uma fiscalização de rotina. Fernando não dificultou as buscas realizadas no imóvel.

A testemunha de Defesa, Lucas, agora ouvido em juízo, mudou a versão. Alegou então que estava com o Josemaik no carro. As drogas estavam dentro da bolsa da menina. Josemaik o buscou, passaram na firma para ele soltar os cachorros. Em seguida, foram na Tabacaria, local em que encontraram o restante do pessoal. Conhecia o Vítor, jogavam bola juntos. Após conversarem na tabacaria, resolveram voltar para a casa. Josemaik passou na casa de outra pessoa, ele desceu do veículo para buscar o moleque. Também desembarcou do carro, foi para o banco de trás. A viatura se aproximou e os abordou. A menina ficou desesperada. Não sabia o que ela fez, apareceram drogas, que eram dela. Não portava drogas. Josemaik não estava com entorpecentes. As drogas foram encontradas na bolsa da Sabrina.

Vítor Hugo Onagaro, reinquirido em juízo, igualmente inovou na versão, em se considerando o dito imediatamente, no flagrante. Alegou que presenciou quando os policiais revistaram o carro e falaram que acharam as drogas. Não tinha entorpecentes dentro do veículo. Localizaram drogas dentro da bolsa de uma menina que os acompanhava. Portava quatro buchas de maconha, explicou na Delegacia que era usuário de drogas. Os entorpecentes encontrados no veículo estavam dentro da bolsa da Sabrina, mas não sabia precisar a quantidade. As drogas eram de responsabilidade da Sabrina, estavam na bolsa dela. Viu quando a mulher pegou a bolsa e a jogou de lado, logo ela saiu do carro 'a milhão'. Não viu a Sabrina jogar nada. Conhecia o Fernando apenas de 'de vista'.

Por fim, Daniele Bissoli, também arrolada pela Defesa, explicou que trabalhava com o Josemaik há dois anos. Tratava-se de pessoa trabalhadora, ele tinha as chaves da empresa, pois era encarregado, pessoa de confiança do seu patrão. Desconhecia qualquer fato que o desabone. Josemaik tinha livre acesso no trabalho, até cuidava dos cachorros.

A prova testemunhal permite concluir, assim, que ambos os réus mantinham sob suas responsabilidades, transportando no veículo ou mantendo em depósito na casa, drogas, as quais, as do veículo, pela quantidade e forma de disposição, não indicam destinação outra senão a do tráfico. As encontradas na casa, por igual, sendo variadas, em quantidade ainda mais expressiva e dispostas também em porções, são confessadamente para o tráfico.

Os réus foram abordados após os policiais avistarem as testemunhas Lucas, Victor e Sabrina tentarem se ocultar na parte de trás do carro.

Em face de atitude anormal, abordaram, revistaram e lograram apreender um tanto de droga, quatorze porções, jogadas no assoalho do carro e próximo a Lucas. No porta-malas, agora perto estepe, acharam mais vinte e oito porções da mesma droga, maconha, dispostas em kits.

É certo que todos os abordados, que são as testemunhas referidas, trataram logo de negar qualquer implicância com a droga apreendida, tanto a do assoalho quanto a do porta-malas, excetuado quatro porções apreendida com Victor, que adiantou ser para seu consumo.

Sabrina, em juízo, negou que tivesse responsabilidade pela droga apreendida no carro, embora sem qualquer credibilidade as testemunhas Lucas e Victor, reinquiridas em juízo e com a garantia do contraditório, tentassem fazer crer (ao contrário do que alegaram no flagrante) que a droga teria sido encontrada na bolsa de Sabrina.

Os policiais, harmônico ao que as testemunhas, incluindo Sabrina, disseram no inquérito, em juízo asseguraram que nada foi encontrado na bolsa da mulher. Estavam ou de posse de Victor, que assumiu ser para uso ou jogadas no assoalho (próximo a Lucas) e no porta-malas, em kits, perto do estepe.

O carro era mesmo de responsabilidade de Josemaik, que o conduzia e foi também apontado pelas testemunhas como sendo o seu motorista, momentaneamente ausente

porque foi até Fernando.

Assim, Josemaik deve responder pelo crime de tráfico, na exata medida em que a droga apreendida no carro era de sua responsabilidade, para traficar porque ocultadas em carro de terceiro, dispostas individualmente, também em kits.

Fernando também tinha as drogas na casa, confessou a conduta e o tráfico, assim como foi sua confissão respaldada pelos depoimentos das testemunhas policiais.

A quantidade da droga, a forma como acondicionada, os apetrechos e as embalagens, só evidenciam o elo entre os réus, bem como o desiderato de traficar.

A versão dos policiais militares, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES.

Mesmo que não houvessem sido pilhados vendendo a droga, a denúncia é certa em acusar de trazer com eles e guardar drogas, para tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

"Para a configuração do crime previsto no art. 12 da Lei n.6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente tenha em seu poder a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a 'traditio' para a consumação do delito" (Proc. 1462767/0, Ap. TACrim, 14ª. Câ. Rel. Wilson Barreira, j. 31.3.2005, vu, rolo/flash 3004/076; no mesmo sentido, Ap. 1467361/7, Jacareí, 14ª Câ. Crim TACRIM SP).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Fernando limitou-se a alegação de não ser o proprietário do entorpecente e que apenas o guardou para terceira pessoa porque passava por dificuldades financeiras. A sua versão, de todo o modo, não o autoriza ou permite a guarda de drogas, na quantidade e variedade, para tráfico, que confessou iria ser entregue para terceiro (que não identificou).

Josemaik negou qualquer envolvimento com os entorpecentes apreendidos na casa ou no seu carro, mas como já sublinhado, a negativa é inconsistente, sequer amparada pelas novas oitivas de Lucas e Victor, em juízo, que prestaram versões totalmente dissonantes daquelas apresentadas no inquérito, com intuito notório de favorecer, de modo mendaz, a Josemaik.

Indiferente a alegação dos réus de que não teriam envolvimento com o tráfico, na conduta de vender o entorpecente, na medida em que a acusação é certa de imputar a eles a conduta de trazer com eles e guardar, para esse fim, drogas.

Ser sequer fizeram prova da versão exculpatória, como lhe incumbiam.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial

é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

A respeito, já se decidiu que "de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado." (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).

Incabível, portanto, o reconhecimento de inexigibilidade de conduta porque não comprovado que o meio escolhido era o único disponível diante da situação.

Nesse sentido:

Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Acusação pugna pelo afastamento da redutora do §4 do art. 33. Privilégio mantido, com fração reduzida. Réu primário e portador de bons antecedentes. Regime inicial alterado para o semiaberto. Grande quantidade e variedade de drogas. Tese de inexigibilidade de conduta diversa não acolhida. Não comprovação de que, de fato, o meio escolhido era o único disponível diante da situação. Confissão que já foi reconhecida, mas sem reflexo na pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não permitida. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1503966-14.2018.8.26.0050, 7ª Câmara de Direito Criminal; J. em 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 32/34), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 35/40), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 145/149) e pelo laudo pericial de fls. 265/268).

Por isso de rigor a condenação.

Fixação das penas.

Os réus são reincidentes (Josemaik vg. Processo nº 1500710-69.2018.8.26.0533 - 2ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP (0002983-57.2019.8.26.0502 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP), incurso no Art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I (duas vezes) c/c Art. 14, II ambos do Código Penal e Art. 288-A, "caput", todos do CP, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/12/2019) (Fernando vg. Processo nº 0000164-25.2017.8.26.0630 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP (0015412-27.2017.8.26.0502 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP), incurso no Art. 33 "caput" do SISNAD; com trânsito em julgado para a Defesa em 19/06/2018), o que será considerado na segunda fase.

Fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, concorre a agravante da reincidência (Josemaik vg. Processo nº 1500710-69.2018.8.26.0533 - 2ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP (0002983-57.2019.8.26.0502 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP), incurso no Art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I (duas vezes) c/c Art. 14, II ambos do Código Penal e Art. 288-A, "caput", todos do CP, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/12/2019) (Fernando vg. Processo nº 0000164-25.2017.8.26.0630 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP (0015412-27.2017.8.26.0502 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP), incurso no Art. 33 "caput" do SISNAD; com trânsito em julgado para a Defesa em 19/06/2018), exaspero a pena em mais um sexto. Fernando é confesso.

Em 19 de outubro de 2015, foi publicada a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual se assentou o entendimento de que nas hipóteses em que a condenação criminal do réu basear-se em algum elemento de sua confissão, este fará jus à redução de pena prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal.

A Súmula apresenta a seguinte redação: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal". Compenso as circunstâncias, mantendo a pena fixada em primeira fase para o réu Fernando.

Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque reincidentes. E a pena final, por si, impõe óbice a

substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou 'sursis'. Os réus deverão cumprir pena no regime inicial fechado, pela mesma reincidência. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar: a) FERNANDO SOARES MACHADO às penas de cinco (05) anos de reclusão, regime inicial fechado e quinhentos (500) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' da Lei 11.343/2006 c.c. artigos 61, I e 65, III, 'd', ambos do Código Penal; e, b) JOSEMAIK DE OLIVEIRA SANTOS às penas de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, regime inicial fechado e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' da Lei 11.343/2006, c.c. artigos 61, I, do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Condeno os réus nas custas do processo, que arbitro em 100 UFESPs, para cada qual, na medida em que constituíram advogados, sem comprovação de que fossem hipossuficientes.

Após o trânsito em julgado, inscrevam-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Consoante concordância ministerial (fls. 191), vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, à exceção do veículo.

Não há prova de que o veículo, que é de terceiro e era momentaneamente utilizado por Josemaik, fosse com anuência da proprietária, usado para o transporte de drogas.

Autorizo, quanto aos objetos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto a destruição da droga.

Presos preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo reclusos, devem assim permanecerem, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública, rotineiramente abalada por crimes de gravidade e hediondo, como o tráfico. Interessa a sua prisão para a eficaz aplicação da lei penal, especialmente porque são reincidentes, indicando que há efetiva probabilidade de reiteração delitiva acaso soltos.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

"Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo" (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).

Eventual liberação de veículo dependerá de requerimento do interessado proprietário, com documentação idônea a respeito da propriedade.

Recomendem-se.

P.I.C.

Americana, 18 de outubro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA